

1509509-07.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509509-07.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509509-07.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109302/2022 - 91º D.P. CEASA, 24462622 - 91º D.P. CEASA, 2109302 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID RODRIGUES ELÍDIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

DAVID RODRIGUES ELÍDIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Isso porque, no dia 22 de abril de 2022, por volta das 10h00min, na Avenida Presidente Altino, altura do numeral 6640, Ind. Autonomista, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, o acusado trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, no interior de um estojo, 25 papéletes contendo cocaína, com peso líquido de 11,8g; 11 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 1,7g; 35 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 6,2; 16 invólucros plásticos contendo o entorpecente vulgarmente conhecido por "maconha", com peso líquido de 27,1; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia

de R\$ 146,00, em espécie, proveniente da venda de drogas.

Narra a denúncia que no dia dos fatos, o denunciado deliberou por praticar o comércio ilícito de entorpecentes no local supra referido, conhecido como 'ponto de venda de drogas'. Ocorre, todavia, que policiais militares durante patrulhamento de rotina aportaram nas proximidades e visualizaram o denunciado sentado, o qual, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga, abandonando uma 'pochete' ao solo. Após brevíssima perseguição, o denunciado foi detido e, após revista pessoal, os policiais localizaram um aparelho celular em sua posse. Além disso, no interior da 'pochete' foram localizados os entorpecentes e o dinheiro supra referidos.

Indagado, confessou informalmente aos policiais que estava no local vendendo drogas. Por fim, os policiais lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram ao Distrito Policial. Interrogado, permaneceu em silêncio.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida por despacho no dia 20 de junho de 2022 (fls. 127/129). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 150), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 70/78; 114/116). Ausentes as hipóteses autorizadoras da absolvição sumária, designei audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 19 de agosto de 2022 (fls. 127/129).

Durante a instrução de causa, foram ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em debates orais tendo a Douta Promotora pleiteado pela condenação do acusado nos termos da denuncia bem como pela não aplicação do redutor e regime fechado.

A nobre Defesa, diante da confissão, não requereu a absolvição mas sim a aplicação do redutor em seu grau máximo, regime aberto, substituição da pena corporal e recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 33/35); o auto de prisão em flagrante (fls. 04 e 24); o auto de exibição e apreensão (fls. 21/22); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 41/44; 82/83).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.21/22) e dos laudos de constatação provisória (fls.27/31 ), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substancia entorpecente (fls.156/159), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Policia! Lucas recordou-se do acusado de uma ocorrência de trafico de drogas.

Estava em patrulhamento pela área do batalhão e se deparou com individuos o local em uma biqueira já conhecida. Viu uma movimentação no local que é um pontilhão.

Alguns moradores moram ali. Desembarcaram e ao chegarem no local o acusado se assustou e tentou sir do sofá que estava sentado. Em diligencia rápida no entorno do sofá, encontrou a pochete exatamente atrás de onde ele estava sentado, ou seja, no chão, logo atrás do encosto. Não chegou a ver a pochete na mão mas a pratica é colocar próximo. Indagada, ele cooperou a todo momento. Ele admitiu que estava desempregado e recorreu ao meio ilícito para fazer dinheiro. Antes de desembarcar da viatura, chegou a vê-lo conversando com duas ou mais pessoas. Distante de onde ele estava, havia outros moradores. Pelo que se recorda, não havia outras pessoas no entorno dele. Ele disse que trabalhava em um lava-rápido e como ficou desempregado, recorreu a isso. Era recente.

De igual forma, o policial Ivan reconheceu o acusado. Em patrulhamento pelo local e em determinado momento se deparou com o rapaz. Ele tentou fugir mas não conseguiu.

Em varredura localizou uma pochete atrás do sofá com entorpecente e dinheiro. O entorpecente estava fracionado para venda. A única pessoa que estava melhor vestida ali era ele. Quando o visualizou ele estava próximo ao sofá e da pochete. Não se recorda mas acha que ele não estava sentado no sofá. Ele admitiu que estava na posse da droga e na venda.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão do acusado obtida em juízo, vejamos.

David tem 23 anos. Mora com a esposa mas não tem filhos. Estava fazendo bico no CEASA. A esposa não trabalha. Nunca foi processado depois que atingiu a maioridade e quando menor foi processado por tráfico por duas vezes. Uma delas foi absolvido. Reconhece a droga como sendo sua e que estava ali para vender droga. Não usa entorpecente. A esposa tem 18 anos de idade. O entorpecente estava onde o policial disse. Está arrependido e pretende voltar a trabalhar em um trabalho digno. A confissão de Davi vai de encontro a toda prova produzida. Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está incluído no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, afasto a agravante referente a calamidade pública eis que, a meu sentir, não houve prova alguma de que o circunstancia tenha agravado o crime ou facilitado sua prática. Não há prova de nexo causal. De igual forma, a confissão e a menoridade relativa não serão utilizadas para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.29/31. Não se pode presumir, de outra banda, que

ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno DAVID RODRIGUES ELIDIO, nascido em 03/06/1999, natural de Não Informado - filho de Marco Rogerio de Jesus Elidio e Cristiane Rodrigues, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão

das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal. O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls.21/22). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado.

Isento de custas. Sentença publicada em audiência.

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA